bkl 법무법인(유한)태평양
03161 서울시 종로구 우정국로 26
T 02 3404 0000 F 02 3404 0001 bkl@bkl.co.kr

MEMORANDUM

본 문서는 변호사법상 변호사와 의뢰인 간 비밀유지권이 적용됩니다(Attorney-Client Privileged).

2026. 10. 08.

수 신: 코람코자산신탁 주식회사
참 조: 임영규 부장님 /리츠투자부문 상장리츠본부 상장리츠팀
발 신: 변호사 강현, 박재화 / 법무법인(유한) 태평양
제 목: 신설리츠 투자구조에 대한 검토

I. 검토의 배경 및 질의의 요지

1. 검토의 배경

귀사는 부동산투자회사법(이하 "**부투법**")에 따른 자산관리회사로서, 부동산투자회사(이하 "**신설리츠**")를 새로 설립하고, 신설리츠를 통해 코크렙안양 주식회사(이하 "**매도인**")가 소유하고 있는 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 토지 및 해당 토지 소재 코크렙 안양물류센터(이하 "**본건 부동산**")를 매입하는 거래(이하 "**본건 거래**")를 추진하고자 합니다.

신설리츠의 주식은 본건 거래의 거래종결 시점까지 제1-1종 우선주, 제2-1종 우선주, 제2-2종우선주, 제3종 우선주 및 보통주가 발행될 예정이고, 신설리츠의 투자자 구성은 다음과 같이 진행될 예정입니다.

- ❍ 제1-1종 우선주: 우리투자증권 주식회사 참여 확정
  - 공모예외기관[1]의 매입확약서* 조건부 인수확약서(LOC) 제출 완료
    *매입확약서 주요사항: 공모예외기관이 2년 내 제1종 우선주 매입완료의무[2]
- ❍ 제2-1종, 제2-2종 우선주: 삼성증권 주식회사 참여 확정
  - 공모예외기관의 매입확약서* 조건부 인수확약서(LOC) 제출 완료
    *매입확약서 주요사항: 공모예외기관이 1년 내 제2종 우선주 매입완료의무
- ❍ 제3종 우선주: 양해각서 체결 후 매도인이 재투자 예정

[1] 주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(이하 "**KLI**")를 말합니다.

[2] 다만 공모예외기관의 우선주 매입 방식은 유상증·감자 방식의 가능성도 열어둘 계획이며, 아래 제2-1종, 제2-2종 우선주도 동일합니다.

- 매도인이 본건 거래에 관한 부동산매매계약(이하 "본건 매매계약")상 계약금 채권(100억원)과 신주인수대금 채무를 상계하는 방식으로 주금납입 예정 (계약금 지급기일과 제3종 우선주의 주금납입기일은 모두 거래종결일 2영업일 전으로 정하고, 잔금 2,600억원은 거래종결일에 지급 예정)
- 발행일로부터 24개월까지 신설리츠에서 발행가액으로 유상감자 계획
- 매도인은 주식회사 엘에프(이하 "**LF**")가 발행주식의 95%를 보유한 LF의 계열회사
- 무의결권, 무배당(단, 신설리츠의 출자자 간에 체결하는 주주간계약(이하 "**주주간계약**")에 따른 감자약정기한까지 유상감자가 완료되지 않는 경우 정관이 정하는 바에 따라 조건부 누적적 우선배당 및 자산매각 요청권 부여 예정)

❍ 보통주: 공모예외기관 참여 예정

- 잔여배당 (단, 설립 후 1년간 7.5% 확정배당)

이때 공모예외기관(KLI)은 신설리츠의 최초 설립시 3억원의 설립자본금을 출자하여 보통주를 취득한 후, 본건 거래의 거래종결 시점에 타 투자자들과 함께 신설리츠의 유상증자에 참여하여 보통주(148억원)를 추가 취득할 예정이며, 신설리츠는 공모예외기관이 최초 설립시 취득한 보통주(3억원)에 대해서는 유상감자를 진행할 예정입니다.

신설리츠의 유상증·감자를 통해, 본건 거래의 거래종결 시점에 신설리츠의 주주는 다음과 같이 구성될 예정입니다.

(액면가액: 1,000원)

종류	주주	발행가액(원)	출자금액(원)	보유주식수(주)	지분율	의결권 비율	의결권
보통주식	KLI	5,000	14,800,000,000	2,960,000	46.58%	58.73%	O
제1-1종 종류주식	㈜신한은행(이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자로서)	25,000	10,000,000,000	400,000	6.29%	7.94%	O
	키움캐피탈㈜	25,000	6,000,000,000	240,000	3.78%	4.76%	O

	㈜애큐온캐피탈	25,000	5,000,000,000	200,000	3.15%	3.97%	O
	엠지캐피탈㈜	25,000	3,000,000,000	120,000	1.89%	2.38%	O
제2-1종 종류 주식	KLI	25,000	16,000,000,000	640,000	10.07%	12.70%	O
	삼성증권㈜	25,000	12,000,000,000	480,000	7.55%	9.52%	O
제2-2종 종류 주식	㈜신한은행(이지스리츠포트폴리오 일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자로서)	25,000	10,000,000,000	400,000	6.29%	-	X
	기계설비건설공제조합	25,000	12,000,000,000	480,000	7.55%	-	X
제3종 종류 주식	매도인	23,000	10,000,009,000	434,783	6.84%	-	X
	합계		98,800,009,000	6,354,783	100.0%	100.0%	-

2. 질의의 요지

이와 같은 배경하에서 귀사는 아래의 사항들을 질의하셨습니다.

(1) 신설리츠의 정관 및 주주간합의서 상 아래의 내용을 반영하는 경우 문제가 없는지 또는 추가 보완할 수 있는 점

(i) 최초 설립 시(영업인가 전) 자본금 3억원 공모예외기관에서 출자함.
(ii) 정관 상 공모예외기관에 이사회의 이사 3인 중 2인을 선정할 권한을 부여함[3]
(iii) 상법 상 무의결권 비율 25%를 제1종 우선주(제1-1종, 제1-2종), 제2종(제2-1종, 제2-2종) 우선주 및 제3종 우선주에 분배, 부여함.

[3] 현재 귀사가 신설리츠의 법인이사를 하는 방안은 고려하고 있지 않으므로, 그 방안에 대한 검토는 생략하겠습니다.

(2) 매도인이 신설리츠의 제3종 우선주에 대해 재투자 참여 시, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "**공정거래법**") 등 관련 법령 상 귀사, KLI 또는 신설리츠에게 법적 리스크가 있는지 여부 및 (있는 경우) 그 리스크를 햇징할 수 있는 방법

(3) 매도인이 제3종 우선주의 인수대금 납입채무를 본건 매매계약상 계약금 채권과 상계하는 방식으로 납입하는 것이 상법 및 부투법 등 관련 법령상 허용되는지 여부

II. 본 법무법인의 의견의 요지

(1) 정관 및 주주간합의서 상 귀사가 고려하는 내용을 반영하는 경우 법률상 특별한 문제는 없을 것으로 판단됨.

(2) (i) 매도인의 제3종 우선주 재투자는 본건 거래의 종결을 통해 본건 부동산의 매매대금 대부분을 조기에 회수하기 위한 거래조건의 일부로 이해되고, 매도인이 재투자에 따른 자금회수 위험을 부담하는 대신 매각 지연에 따른 부담을 줄이고 매매대금을 확보하는 직접적인 경제적 이익을 얻는다는 점에서 매도인 자신의 이익을 위한 합리적인 경영상 판단에 따른 것으로 볼 수 있으므로, 매도인의 제3종 우선주 재투자가 부당지원행위에 해당할 가능성은 낮을 것으로 판단됨. 또한 입찰시 매도인의 특정 계열회사만 충족할 수 있는 조건을 제시한 경우 형식적 입찰로 평가되어 부당지원행위에 해당할 리스크가 있는데, 입찰시 귀사가 제시한 제3종 우선주 투자 조건이 귀사 외에 다른 입찰 참가자들도 충분히 제시할 수 있는 조건이라면, 형식적 입찰로 평가되어 부당지원행위에 해당할 리스크는 낮음. (ii) 매도인만을 대상으로 감자를 실시함에 있어서 그 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 결과적으로 매도인이 감자에 참여하지 않은 신설리츠의 다른 주주들(감자 당시 매도인의 특수관계인임을 전제로 함)에게 이익을 분여한 결과가 되어 부당행위 계산 부인이 문제될 수 있음. 다만, 매도인이 본건 거래를 성사시키기 위한 목적으로 제3종 우선주 재투자 및 감자를 통한 원금 회수에 대한 의사결정을 한 경우, 이러한 행위에 이익 분여 목적이 있다고 보기 어렵다고 판단되며, 경제적 합리성을 갖춘 거래로 부당행위계산 부인

대상이 아님을 주장할 수 있다고 판단됨.

(3) 상법 제421조 제2항에 따라 회사의 동의가 있으면 신주의 인수인은 회사에 대한 채권으로 주금납입채무와 상계할 수 있음. 본건에서 상계의 대상이 되는 계약금 채권은 본건 매매계약에 따라 금액이 확정되고 그 지급기일이 주금납입기일과 같은 금전채권이므로, 신설리츠가 동의하는 한 매도인의 상계납입은 상법상 허용되고 자본충실의 원칙에 반한다고 보기도 어려움. 또한 상계납입은 현물출자와 구별되는 제도이므로 부투법 제19조의 현물출자 제한이 적용되지 않는 것으로 판단되며, 같은 조 제1항의 취지를 고려하더라도 본건에서는 상계납입분을 제외한 현금 출자만으로 최저자본금(50억원) 이상이 같은 날 납입되므로 위 규정에 저촉될 가능성은 낮을 것으로 판단됨.

III. 본 법무법인의 의견에 대한 설명

1. 질의사항 (1)에 대한 의견

가. KLI의 최초 자본금 3억원 납입

1) 가능 여부

신설리츠는 최초에 (법무사 등 제3자가 아닌) KLI가 자본금 3억원을 납입하여 KLI가 신설리츠의 100% 주주가 될 예정이며, 해당 시점에 신설리츠는 KLI의 공정거래법 상 계열회사가 될 예정입니다. 주주간합의서에 KLI가 위와 같이 최초 자본금 3억원을 납입한다는 내용을 반영하는 것은 가능하며, 이러한 내용이 특별히 법률상 문제되지는 않을 것으로 판단됩니다. 한편, 실무상 정관에 이러한 내용을 반영하지는 않으며, 주주간합의서에 반영하는 것이 일반적입니다.[4]

[4] 정관은 회사의 조직과 활동을 정하는 근본 규칙으로서, 특정 주주 1인의 개별적인 일회성 출자의무를 정관에 규정하는 것은 적절하지 않습니다.

2) 공모간주 이슈

자본시장법은 부투법에 따른 사모리츠로서 투자자가 49인 이하인 경우에는 자본시장법상 집합투자 개념에서 제외되도록 하나, 여기서 투자자 49인 이하인지 여부를 판단함에 있어서 (a) 원칙적으로 사모리츠의 투자자인 공모리츠가 발행총수 100분의 10 이상을 취득하는 경우에는 공모리츠의 투자자의 수까지 더하여야 하고, 다만 (b) 예외적으로 해당 공모리츠가 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액을 합산한 금액이 자산총액의 100분의 80을 초과하는 공모리츠(이하 "**투자자 합산제외 공모리츠**")라면 해당 공모리츠의 투자자 수가 사모리츠의 투자자수에 합산되지 않습니다(자본시장법 제6조 제5항 제1호, 동법 시행령 제6조 제1항 제1호 및 제3항).

KLI의 경우 2026. 2. 28. 기준 총자산의 90.11%가 부동산으로 구성되어 있는 것으로 파악되어 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액이 80%를 초과하는 투자자 합산제외 공모리츠에 해당하지 않습니다.

따라서 투자자 합산제외 공모리츠에 해당하지 않는 KLI가 신설리츠에 대한 발행총수 10% 이상 출자시 KLI의 투자자가 신설리츠의 투자자수에 합산되어 신설리츠는 100인 초과의 투자자가 있는 공모집합투자기구가 되고, 이에 따라 자본시장법의 적용을 받게 됩니다(투자자 합산에 따라 투자자 수가 100인 초과하는 리츠에 대해, 이하 "**공모간주 리츠**").

즉 신설리츠는 매매계약 체결 후 거래종결 전 유상증자를 통해 KLI가 보통주를 취득하는 시점에 공모간주 리츠가 되어 자본시장법의 적용을 받습니다. 한편, 자본시장법은 50인 이상의 투자자에게 모집 또는 매출을 진행하는 경우 자본시장법이 정하는 바에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하도록 하는데(자본시장법 제9조 제7, 9항, 제119조 이하), 투자자 합산제외 공모리츠의 투자로 인해 공모간주 리츠가 되는 경우에도 이러한 증권신고서 제출이 필요한지가 문제됩니다.

관련하여 최근 본 법무법인이 비공식적으로 금융감독원에 확인한 바에 따르

면, 금융감독원은 공모리츠의 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도의 모집이나 매출을 하지 않는 경우라면 증권신고서를 제출하지 않더라도 제재 조치는 현실적으로 어렵다고 보고 있고, 이에 실무적으로 다른 사례에서도 공모간주 리츠가 별도의 증권신고서를 제출하지 않고 있는 상황으로 파악되며 그러한 상황에 변화는 없는 것으로 보입니다.

따라서, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 공모 행위를 하지 않는다면 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 증권신고서를 제출하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

이와 별개로 신설리츠가 공모간주 되는 경우, 해당 시점에 신설리츠가 부투법상 공모의무를 이행하여야 하는 것은 아닙니다.

나. KLI의 이사 선정 권한

현행 K-IFRS 제1110호(연결재무제표)의 문단 7 이하에 의하면, 투자자는 다음 모두에 해당하는 경우에만 피투자자를 지배하는 것으로 보고 있고, 이 경우 투자자는 피투자자의 지배기업이 되고, 피투자자는 투자자의 종속기업이 됩니다.

(1) 피투자자에 대한 힘이 있을 것
   - 이때 투자자가 힘을 가지게 할 수 있는 권리의 예시는 피투자자에 대한 의결권(또는 잠재적 의결권) 형태의 권리, 관련 활동을 지시하는 능력이 있는 피투자자의 주요 경영진 구성원을 선임, 재배치, 해임할 권리, 관련 활동을 지시하는 다른 기업을 선임하거나 해임할 권리 등이 있음.
(2) 피투자자에 관여함에 따라 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있을 것
(3) 투자자의 이익금액에 영향을 미치기 위하여 피투자자에 자신의 힘을 사용하는 능력이 있을 것

현재 우선주 투자자인 증권사들은 유상증자 후 신설리츠가 증권사의 종속기업이 되어 회계상 연결대상이 되는 것을 우려하여 위와 같이 KLI에게 이사회 3인 중 2인 선정 권한을 부여하여 KLI의 신설리츠에 대한 지배력을 인정받고

자 하려는 것으로 이해됩니다.

위와 같이 신설리츠의 정관 상 KLI에 이사회의 이사 3인 중 2인을 선정할 권한을 부여하는 것은 가능하며, 이러한 내용이 특별히 법률상 문제되지는 않을 것으로 판단됩니다.

다만 실제 종속기업 해당 여부(K-IFRS에 따른 지배력 인정 여부) 및 연결 여부는 회계상 검토가 필요한 부분임을 유의할 필요가 있습니다.

다. 무의결권 비율의 분배 관련

상법 제344조의3 제1항에 따르면 회사가 의결권이 없는 종류주식이나 의결권이 제한되는 종류주식을 발행하는 경우에는 정관에 의결권을 행사할 수 없는 사항과, 의결권행사 또는 부활의 조건을 정한 경우에는 그 조건 등을 정하여야 합니다. 또한 상법 제344조의3 제2항에 따르면, 위 제1항에 따른 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못합니다.

귀사는 무의결권 주식의 한도인 발행주식총수의 4분의 1의 범위 내에서, 그 무의결권 주식을 제1종 우선주, 제2종 우선주 및 제3종 우선주에 배분하려는 취지인 것으로 이해됩니다.

그런데 한 종류의 주식에서, 일부는 의결권이 있고, 일부는 의결권이 없는 주식을 발행하는 것은 허용되지 않는다고 해석될 가능성이 높고, 제1종 우선주 내에서 의결권이 있는 주식과 의결권이 없는 주식은 다른 종류의 주식으로 발행되어야 할 것으로 보입니다. 예컨대 누적확정 CoC 7%이고 매각차익 배분이 없는 주식(귀사의 계획상 제1종 우선주)을 발행하고자 하는 경우, 그 중에서 의결권이 있는 주식은 제1-1종 우선주로, 의결권이 없는 주식은 제1-2종 우선주로 발행할 수 있을 것으로 판단됩니다.[5]

현재 귀사가 최종적으로 고려 중이신 방안에 따르면 제1종 우선주를 제1-1종 우선주, 제1-2종 우선주로 세분화하고, 제2종 우선주를 제2-1종 우선주, 제2-2종

[5] 기 송부드린 정관 초안을 참고 부탁드립니다.

우선주로 세분화하며, 이때 제1-2종 우선주와 제2-2종 우선주는 무의결권 주식으로 발행할 예정이며, 그 밖에 제3종 우선주도 무의결권 주식으로 발행할 예정인 것으로 이해되는바, 이러한 방식은 가능할 것으로 판단됩니다.

2. 질의사항 (2)에 대한 의견

가. 상법상 신용공여

상장회사는 주요주주 및 그의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 신용공여를 하여서는 안 됩니다(상법 제542조의9 제1항). 이때 신용공여란, 금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험이 따르는 직접적·간접적 거래로서 대통령령으로 정하는 거래를 말합니다.

신설리츠의 보통주, 우선주에 대한 유상증자가 동시에 이루어진다는 전제 하에, 신설리츠 발행 제3종 우선주를 취득하는 매도인은 상장회사가 아니므로 매도인의 제3종 우선주 취득에 대하여 상법 제542조의9가 직접 적용되지는 않습니다. 또한 매도인은 상장회사인 LF의 계열회사이나, 신설리츠는 LF 또는 매도인과 계열회사 관계에 있지 않고 LF의 주요주주나 그의 특수관계인에도 해당하지 않는 것으로 보이므로, 매도인의 제3종 우선주 취득을 LF의 신설리츠에 대한 간접적인 신용공여로 보아 상법 제542조의9에 따른 신용공여 금지가 문제될 여지도 낮을 것으로 판단됩니다.

참고로, 이해관계인에 해당하는 회사의 유상증자에 참여하여 신주(지분증권)를 인수하는 경우에는 상법 제542조의9에서 말하는 '자금지원적 성격의 증권 매입'에 해당하는지 여부가 문제될 수 있습니다. 이에 대하여 현재로서는 확립된 판례나 유권해석은 확인되지 않고, 학설상으로는 '채무불이행에 따른 신용위험과 관련이 없는 주식 등 지분증권을 취득하는 행위는 신용공여로 볼 수 없다'는 견해가 유력합니다[한국사법행정학회, 주석 상법 제6판, 797면; 김지평, "상장회사 이해관계자 거래규제의 실무상 쟁점, 선진상사법률연구 통권 제81호 (2018. 1.), 122~123면]. 매도인이 신설리츠가 발행한 제3종 우선주를 취득하는 경우, 이는 신용위험과는 관련이 없는 주식이므로 이를 신용공여라고 보기도 어려울 것으로 보입니다.

나. 공정거래법상 부당지원행위

1) 매도인의 재투자 관련 부당지원행위

공정거래법상 부당하게 특수관계인[6] 또는 다른 회사에 대하여 부동산 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 부당한 지원행위(이하 "**부당지원행위**")에 해당하는데(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 이러한 부당지원행위가 성립하기 위해서는 '지원행위'와 '부당성'이 인정되어야 합니다{공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 같은 법 시행령 제52조, 별표 2 제9호 (나)목}.

'지원행위'에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 급부와 반대급부 사이의 차이가 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 '정상가격'이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미합니다(부당한 지원행위의 심사지침 II. 5., Ⅲ. 2. 가. 나.).

공정거래법상, 사업자가 특수관계인 또는 다른 회사에 대여금, **유가증권**이나 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위도 부당지원행위에 해당할 수 있습니다. 예컨대 제3자 배정 또는 실권주(失權株) 인수 등의 방식을 통해 유상증자에 참여하면서 특수관계가 없는 독립된 자가 인수하지 않을 정도의 고가로 발행한 주식을 지분을 전혀 보유하고 있지 않던 지원주체가 인수하는 경우 '지원행위'에 해당할 수 있습니다(부당한 지원행위의 심사지침 III. 2. 가. 참조). 다만, 비상장주식의 "정상가격"이 구체적으로 얼마인지에

[6] 여기서 "특수관계인"이란 당해 회사를 사실상 지배하고 있는 자(즉, 동일인), 동일인관련자, 경영을 지배하려는 공동의 목적을 가지고 기업결합에 참여하는 자를 의미하고(공정거래법 제9조 제1항, 동법 시행령 제14조 제1항), 계열회사도 동일인관련자 범위에 포함되는 것으로 해석됩니다(공정위, 대규모 내부거래 공시 업무 매뉴얼, 7면, 30면 참조). 다만 공정거래법상 부당지원행위는 특수관계인이 아닌 경우에도 적용됩니다.

대해서는 다툼의 여지가 있습니다.[7]

매도인은 신설리츠의 유상증자에 참여하여 신설리츠 발행 제3종 우선주를 취득할 예정인데, 만일 매도인이 외부투자자 및 증권사로부터 신설리츠의 주식을 "정상가격"보다 높은 가격에 인수하는 것일 경우 공정거래법상 매도인의 신설리츠에 대한 부당지원행위에 해당할 가능성이 있으며, 원론적으로는 매도인 입장에서 부당지원행위가 문제될 리스크를 최소화하기 위해서는 객관적으로 평가된 신주발행가액으로 주식을 인수하는 것이 적절합니다. 귀사의 설명에 의하면 제3종 종류주의 주당 발행가액을 상증세법상 평가방법을 참고하여 산정할 예정인바, 이는 발행가액의 객관성을 뒷받침하는 사정이 될 수 있습니다.

나아가, 지원행위의 부당성은 지원주체와 지원객체와의 관계, 지원행위의 목적과 의도, 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익 및 지원기간, 지원행위로 인하여 지원객체가 속한 시장에서의 경쟁제한이나 경제력 집중의 효과 등을 종합적으로 고려하여 공정한 거래가 저해될 우려가 있는지 여부에 따라 판단되고(대법원 2004. 3. 12. 선고 2001두7220 판결 등), 지원의도는 지원행위를 하게 된 동기와 목적, 거래의 관행, 당시 지원객체의 상황, 지원행위의 경제상 효과와 귀속 등 여러 상황을 종합하여 객관적으로 추단할 수 있다는 것이 판례의 입장입니다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004두6099 판결). 따라서 매도인의 본건 유상증자 참여가 단순히 신설리츠에 자금을 지원하기 위하여 이루어진 것인지 여부는 제3종 우선주의 권리내용만을 분리하여 볼 것이 아니라, 매도인이 재투자에 이르게 된 동기와 목적, 본건 거래의 구조 및 그로 인한 경제적 효과의 귀속 등 본건 거래의 제반 사정을 함께 고려하여 판단되어야 할 것입니다.

제3종 우선주는 의결권이 없고, 감자약정기한까지는 배당을 받지 않으며, 감

[7] 신설리츠가 발행하는 주식은 비상장주식으로서, "정상가격" 산정시 (i) 실제 거래사례나 (ii) 유사 거래사례를 찾기 어려우므로 (iii) 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있을 것인데, 위와 같은 상증세법에 따른 평가 방법을 따르는 경우 원칙적으로 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 산정하되(자세한 산정 방법은 상증세법 제63조 제1항 제1호 나목, 동법 시행령 제54조 참조), 사업개시 전 또는 사업개시 후 3년 미만인 법인의 주식은 원칙적으로 순자산가치에 따라 평가합니다(상증세법 시행령 제54조 제4항 제2호).

자약정기한 내에 발행가액으로 감자가 진행될 것으로 보이는데(감자약정기한까지 감자가 완료되지 않는 경우에 한하여 정관이 정하는 바에 따라 조건부 누적적 우선배당 및 자산매각 요청권이 부여될 예정입니다), 이러한 구조만 놓고 보면 매도인은 제3종 우선주 취득 자체를 통해 특별히 어떠한 사업적 이득을 얻는지 불분명하므로, 어떠한 합리적인 근거 없이 100억원 재투자를 결정하여 제3종 우선주를 취득한다면 부당지원행위로 평가될 리스크가 존재할 수 있을 것으로 보입니다.

다만 별도로 제공해주신 사실관계에 의하면, 신설리츠는 향후 자산을 매각하는 시점까지 우선주에 대한 배당 재원이 필요한데, 그 금액이 100억원이며, 이러한 배당재원이 없으면 우선주 투자자 모집이 어려운 상황입니다. 이에 신설리츠는 양해각서 체결 후 매도인 측에 100억원 재투자를 요청하였고, 매도인이 제3종 우선주를 인수하되 그 주금은 매도인이 지급받을 매매대금 채권과 상계하는 방식으로 납입하는 것으로 협의 중인 것으로 이해됩니다.

매도인 입장에서는, (1) 본건 거래를 신속히 종결하여 본건 부동산의 매각대금을 회수할 필요성이 있는 점(본건 거래는 매도인이 당초 사업계획상 예정보다 장기간 본건 부동산을 보유하고 있는 상황에서 매도인 및 그 주주의 조속한 투자금 회수 필요성을 주된 배경으로 추진된 것이고, 매도인은 정관상 목적사업이 본건 부동산에 관한 특정사업으로 한정되어 있어 본건 거래의 종결이 곧 매도인 및 그 주주의 투자금 회수로 이어집니다), (2) 현재 상황에서 위 매각대금 회수를 위해서는 현실적으로 신설리츠에 대한 재투자가 필수적이며(신설리츠의 대주 및 투자자들의 심의가 제3종 우선주 발행을 포함한 현재의 조달구조를 전제로 이루어져, 조달구조를 변경하는 경우 재심의 등으로 거래종결이 지연될 수 있는 것으로 이해됩니다), 이를 통해 매도인은 거래를 성사시키고 위 100억원을 제외한 나머지 매각대금을 거래종결 시점에 현금으로 신속히 회수할 수 있는 점, (3) 위 100억원도 주주간계약에 따라 감자약정기한 내에 유상감자를 통해 발행가액으로 회수하는 것이 예정되어 있고, 감자약정기한까지 회수되지 않는 경우에도 조건부 누적적 우선배당 및 자산매각 요청권을 통하여 회수 가능성을 보완하는 장치가 마련될 예정인 점, (4) 실제로 부동산 매매거래에서 매도인 측의 매수인에 대한 재투자가 빈번하게 이루어지는 점, (5) 입찰과정에서 귀사가 제3종 우선주 발행을 포함한 에쿼티 조달계획을 전제로 제시한 가격이 최고가격이어서 매도인은 귀사(즉 신설리츠)와 거래를 진행할 경우

에 매각대금 전액 회수를 포함하여 최대 이익을 얻을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 매도인의 제3종 종류주 재투자에 대한 의사결정은 본건 부동산의 매각과 연계된 합리적 근거가 있는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 재투자 자금의 회수위험 및 매도인의 존속비용을 감안하더라도, 매각 지연에 따른 보유·금융비용 등의 부담을 줄이고 매매대금 대부분을 조기에 회수할 수 있다는 점에서 매도인에 귀속되는 구체적인 경제적 이익을 인정할 수 있을 것으로 판단됩니다.

즉, 매도인 입장에서 재투자 여부에 관한 판단은 제3종 우선주의 수익률을 다른 투자처의 수익률과 비교하는 문제라기보다는, 재투자를 통하여 최고가격으로 본건 거래를 종결하고 매각대금의 대부분을 즉시 회수하는 방안과 재투자를 하지 않음으로써 본건 거래의 종결이 지연되거나 무산될 위험을 부담하는 방안 사이의 선택이라고 할 것이고, 앞의 방안을 택하는 것은 매도인 자신의 이익을 위한 합리적인 경영상 판단으로 평가될 가능성이 높아 보이며, 매도인이 위 회수자금을 기존 금융부채의 상환이나 주주에 대한 투자금 반환 및 수익 배분 등에 활용할 필요가 있다면 그 합리성이 인정될 가능성이 더욱 높아질 것으로 사료됩니다. 한편 매도인은 LF가 발행주식의 95%를 보유한 회사로서 매도인의 위와 같은 이익은 궁극적으로 그 주주인 LF에도 귀속되는바, 매도인의 재투자를 LF 기업집단 차원에서 신설리츠를 지원하기 위한 것으로 볼 사정도 찾기 어려운 것으로 보입니다.

결론적으로, 위와 같은 본건 거래의 배경, 매도인 재투자의 동기·목적 및 그 경제적 효과의 귀속에 더하여, 신설리츠는 매도인 및 LF의 계열회사에 해당하지 않는 점(위 가. 참조), 제3종 우선주 인수금액(100억원)은 신설리츠 에쿼티 총액(988억원)의 약 10% 수준이고 약 2년 후 회수가 예정된 한시적인 거래인 점 등을 종합하면, 매도인의 재투자가 신설리츠에 대한 부당지원행위에 해당할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 이는 매도인에게 귀속되는 매각대금의 조기 현금화 이익과 재투자 부담을 본건 거래 전체의 맥락에서 고려한 판단이며, 무배당이라는 사정만으로 위 재투자가 부당지원행위에 해당한다고 보기는 어렵다고 판단됩니다.

2) 매도인과 신설리츠 사이의 매매거래 관련 부당지원행위

지난 검토의견에서 설명드린 바와 같이, (i) 매도인의 주요 투자자인 LF는 귀사의 계열회사로서 실질적인 이해 당사자인 점, (ii) 비록 신설리츠의 자본금 납입 주주가 제3자 또는 KLI로서 신설리츠는 매도인의 비계열사에 해당하나 귀사는 AMC로서 매수가격 결정에 대한 주도적 역할을 하게 되며, (담당자는 다르나) 매도인의 AMC로서 귀사가 매도인 측에도 관여하는 점, (iii) 본건 거래를 통해 직접적으로 귀사에게 손익이 귀속되는 형태는 아니나 귀사 역시 AMC로서 간접적 이익을 얻게 되는 측면이 있고, (악의적일 경우) 매도인이 귀사를 지원하거나 귀사가 매도인을 지원하기 위한 거래구조(매매조건)를 취하는 것도 가능한 점 등을 고려할 때, 감정평가를 거치지 않은 매매대금(정상가격을 현저히 벗어나는 가격)으로 거래가 진행될 경우 본건 거래에 대하여 부당지원행위가 적용될 리스크가 있고, 따라서 공정한 입찰로 진행될 필요가 있다고 안내해 드린 바 있습니다. 즉 (i) 입찰 실시가 합리적 의사결정이고, (ii) 공정한 입찰 결과에 따라 낙찰된 경우라면 그 자체로 정상가격에 해당하여 부당지원행위 성립 가능성은 낮습니다.[8]

이와 관련하여, 특정 계열회사(매도인 또는 LF 등)만 충족할 수 있는 조건을 제시하는 경우 형식적 입찰로 평가될 리스크가 있는데, 입찰시 귀사가 제시한 제3종 우선주 투자 조건이 귀사 외에 다른 입찰 참가자들도 충분히 제시할 수 있는 조건이라면, 귀사가 낙찰된 입찰 절차가 형식적 입찰로 평가될 리스크는 낮아 보입니다.

귀사의 설명에 의하면, 귀사의 입찰제안서 상 에쿼티 조달계획에 제3종 우선주가 무의결권, 무배당으로 발행될 예정이라는 점은 기재되어 있지만, 이에 대해 미리 매도인에게 요청하거나 협의한 바는 없고, 양해각서 체결 이후에 매도인 측에 공식적으로 위 제3종 우선주 재투자를 요청 및 협의하였으며, 다른 입찰참가자들도 위와 같이 무의결권, 무배당인 제3종 우선주를 통해 에쿼티를 조달하는 것은 충분히 제시할 수 있는 조건입니다. 이러한 사실관계 하에서는, 귀사가 입찰제안서상 제3종 우선주 투자 조건을 제시한 것만으로 본건 입찰이 불공정한 입찰 내지 형식적 입찰로 평가될 리스크는 상대적으로 낮아 보입니다.

[8] 2026. 7. 14.자 Compliance Guideline 참조

다. 세법상 부당행위계산 부인

매도인이 신설리츠가 발행하는 주식을 취득하는 거래, 향후 감자절차를 통해서 Exit 하는 거래는 신설리츠와 주주들 사이에 이루어진 자본 거래에 해당하므로 본건 리츠 단계에서는 특별한 과세문제는 없을 것으로 판단됩니다.

다만, 특정 주주만을 대상으로 불균등 증자 또는 불균등 감자 거래를 실시하는 경우로서 증자대가(감자대가)가 세법상 시가와 다르게 결정되는 경우에는 주주들간의 이익분여 문제가 발생할 수 있습니다. 법인세법은 이러한 자본거래를 통하여 특수관계가 성립하는 다른 주주들에게 이익을 분여한 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되는 것으로 규정하고 있습니다(법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 및 제8호의 2).

예컨대 매도인만을 대상으로 감자를 실시함에 있어서 그 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 결과적으로 매도인이 감자에 참여하지 않은 신설리츠의 다른 주주들(매도인의 특수관계인임을 전제로 함)에게 이익을 분여한 결과가 초래될 수 있습니다.

본건의 경우 매도인과 신설리츠의 다른 주주 사이에 감자 당시 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면, 매도인의 감자거래에 대하여 부당행위계산 부인 규정 등이 문제되지는 않을 것으로 판단됩니다.

만약 매도인이 KLI의 발행주식총수의 1% 이상을 소유하고 있다면 매도인과 KLI는 법인세법상 특수관계인에 해당하므로(법인세법 제2조 제12호, 동법 시행령 제2조 제8항 제2호), 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 위 부당행위계산 부인이 문제될 수 있습니다. 매도인은 KLI의 주식을 보유하고 있지 않은 것으로 이해되고, 매도인과 같은 LF 기업집단 소속 계열회사인 귀사가 KLI 발행주식의 5.23%를 보유하고 있으나, 이는 귀사와 KLI 사이의 특수관계 사유일 뿐이고, 이러한 사정만으로 매도인과 KLI 사이에 법인세법상 특수관계가 성립한다고 보기는 어려울 것으로 판단됩니다.

이와 관련하여 대법원은 부당행위계산 부인 규정은 경제인의 입장에서 볼 때

부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로 인하여 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이고, 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하여야 한다는 입장입니다(대법원 2007. 12. 13. 선고, 2005두14257 판결; 2010.10.28. 선고, 2008두15541 판결 등 참조).

매도인은 본건 부동산의 소유자로서 본건 거래를 성사시킴으로써 매매대금 대부분을 조기에 현금화하기 위한 목적으로 제3종 우선주 투자자로 참여하고 향후 감자거래를 통하여 재투자금의 회수를 추진하는 것으로 이해됩니다. 따라서 이러한 경위를 설명할 수 있는 자료 등을 구비한다면 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우에도 특수관계인에 대한 이익 분여 목적이 있다고 보기 어렵고, 경제적 합리성이 인정되는 거래로 부당행위계산 부인 대상이 아님을 주장할 수 있다고 판단됩니다.

3. 질의사항 (3)에 대한 의견

가. 상법상 주금의 상계납입 허용 여부

부투법 제3조 제2항은 부동산투자회사가 부투법에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 상법의 적용을 받도록 규정하고 있습니다. 상법 제421조 제2항은 신주의 인수인이 회사의 동의 없이 주금납입채무와 회사에 대한 채권을 상계할 수 없도록 규정하고 있으므로, 회사가 동의하는 경우에는 신주인수인이 회사에 대하여 가지는 금전채권으로 주금납입채무를 상계하는 것이 허용됩니다. 대법원도 「주금납입채무의 상계가 있는 경우 신주발행으로 인한 변경등기신청서에 첨부할 서면에 관한 예규」(등기예규 제1450호)를 마련하여 상계납입에 따른 신주발행 변경등기를 허용하고 있습니다.

본건의 경우 (i) 매도인의 계약금 채권은 신설리츠가 당사자로서 체결하는 본건 매매계약에 따라 발생하는 금전채권으로서 그 존재와 금액(100억원)이 명확하고, (ii) 계약금의 지급기일과 제3종 우선주의 주금납입기일이 같은 날이어서 그 날에 양 채무의 이행기가 모두 도래하므로 상계의 요건(민법 제492조 제1항)을 갖추게 되며, (iii) 상계로 인하여 신설리츠는 같은 금액의 계약금 지급채무를

면하게 되므로, 신설리츠의 재산상태는 매도인으로부터 주금 100억원을 현금으로 납입받아 이를 계약금으로 지급한 경우와 다르지 않습니다. 이와 같이 본건 상계납입은 실재하는 채권과의 상계로서 납입의 외관만을 갖춘 가장납입과는 구별되고, 자본충실의 원칙에 반한다고 보기도 어렵습니다. 따라서 신설리츠가 상계납입에 동의하는 것을 전제로 매도인이 신설리츠에 대한 계약금 채권으로써 제3종 우선주 신주인수대금을 상계납입하는 것은 상법상 허용되는 것으로 판단됩니다.

나. 부투법상 현물출자 제한의 적용 여부

부투법 제19조 제1항은 영업인가를 받거나 등록을 하고 제10조에 따른 최저자본금 이상을 갖춘 후에 현물출자를 받는 방식으로 신주를 발행할 수 있도록 규정하고 있습니다. 같은 조 제2항은 현물출자가 가능한 재산을 부동산, 부동산의 사용에 관한 권리, 일정한 부동산신탁 수익권, 부동산소유권의 이전등기청구권 등으로 제한하고 있고, 일반적인 금전채권은 이에 포함되어 있지 않습니다. 상계납입도 금전채권이 출자금으로 전환된다는 점에서 금전채권의 현물출자와 경제적 효과가 유사하므로 위 규정이 적용되는 것이 아닌지 의문이 있을 수 있습니다.

그러나 (i) 부투법 제19조는 문언상 "현물출자"만을 규율하고 있으며 부투법에 상계납입을 제한하는 규정은 없고, (ii) 상법은 현물출자(제416조 제4호, 제422조)와 상계납입(제421조 제2항)을 별개의 조항에서 규율하고 있고, 금전채권의 현물출자가 가능하였던 기존 상법하에서 2011년 상법 개정으로 제421조 제2항을 별도로 도입하여 회사의 동의에 따른 상계납입을 허용한 취지를 고려하면 양자는 개념상 구별되는 서로 다른 제도로 볼 수 있으며, (iii) 등기실무상으로도 상계납입에 따른 변경등기에는 상계를 증명하는 서면을 첨부하도록 하고 있을 뿐 현물출자에 요구되는 검사인의 조사 등(상법 제422조)을 거쳤음을 증명하는 서류는 요구하지 않습니다. 따라서 상법 제421조 제2항에 따른 상계납입에 부투법 제19조 제1항의 현물출자 시기 제한이나 같은 조 제2항의 현물출자 대상 재산 제한이 적용되지 않는 것으로 해석함이 타당하다고 판단됩니다.

관련하여, 위탁관리 부동산투자회사인 주식회사 하나트러스트제7호위탁관리부동산투자회사(이하 **"하나트러스트제7호리츠"**)의 투자보고서상 '자본금 변동

현황' 및 2022. 11. 9.자 이사회 및 임시주주총회 의사록 기재에 따르면, 하나트러스트제7호리츠가 발기설립(자본금 3억원) 이후 진행한 최초 유상증자 시에 매도인(주식회사 자연공간)에 대한 부동산매매대금 중 계약금 지급채무를 매도인의 주금납입채무와 상계하는 방식으로 매도인에게 신주를 발행한 사례도 확인됩니다.

다만 상계납입에 대한 부투법 제19조 제1항의 적용 여부에 관하여 국토교통부 또는 한국부동산원이 명시적인 해석을 밝힌 바는 확인되지 않는바, 최저자본금에 미달하는 상태에서 상계납입으로 신주를 발행하는 구조에 대하여는 감독당국이 신중한 입장을 취할 가능성이 있어 보입니다.

그러나 부투법 제19조 제1항의 취지를 고려하더라도, 본건의 경우 (i) 본건 유상증자는 신설리츠의 영업인가 이후에 이루어지고, (ii) 제3종 우선주와 같은 납입기일에 매도인 외의 주주들이 합계 888억원(발행가액 기준)을 현금으로 납입하며, (iii) 자본금(액면가액 기준)으로 보더라도 본건 유상증자로 증가하는 자본금 약 63.5억원 중 본건 상계납입분(약 4.3억원)을 제외한 약 59.2억원이 현금출자분이어서 해당 출자금만으로도 최저자본금 50억원을 상회합니다. 즉 본건 상계납입은 최저자본금 이상의 현금 출자가 함께 이루어지는 가운데 그 일부로서 이루어지는 것이어서, 최저자본금과 유동성을 먼저 확보하도록 한 부투법 제19조 제1항의 취지에 반한다고 보기 어려운바, 본건 상계납입이 부투법 제19조에 저촉될 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

다. 관련 절차

본건 상계납입을 위해서는 (i) 신설리츠의 이사회가 제3종 우선주의 발행사항을 정하면서 그 주금을 본건 매매계약상 계약금 지급채무와 상계하는 방식으로 납입받는 데 동의하는 결의를 하고(매도인도 필요한 내부절차를 거쳐야 합니다), (ii) 신설리츠와 매도인이 납입기일에 계약금 채권과 주금납입채무를 대등액에서 상계한다는 합의를 주식인수계약 또는 별도의 합의서로 체결하며, (iii) 증자등기 신청 시 등기예규 제1450호에 따라 신설리츠가 매도인에 대하여 채무를 부담하고 있음을 증명하는 서면(본건 매매계약서 등), 상계의 의사표시 및 이에 대한 회사의 동의를 증명하는 서면 등을 첨부하여야 합니다.

이상과 같이 저희 의견을 드리오니 업무에 참고하시고, 다른 의문이나 요청사항이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

(유의사항) 이 MEMORANDUM은 의뢰인에게 법적 조언을 제공하기 위하여 준비되었습니다. 이 MEMORANDUM은 의뢰인 및 의뢰인 소속 개인으로서 이 MEMORANDUM의 내용을 알아야 할 필요가 있는 사람이 사용하기 위한 것입니다. 권한 있는 자에 의한 승인 없는 이 MEMORANDUM의 검토, 사용 또는 배포는 금지됩니다. 의뢰인이 이 MEMORANDUM 또는 그 사본을 제3자에게 제공하고자 하는 경우 사전에 본 법무법인의 동의를 받아야 합니다. 이 MEMORANDUM의 제3자에 대한 제공은 변호사와 의뢰인 간 비밀유지권을 포함하여 관련 법령상 권리의 상실을 초래할 수 있습니다.

법무법인(유한)태평양

변호사 강 현

변호사 박 재 화